La triple clasificación de contratos en el nuevo Código.

El texto del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26.994, que entró en vigencia el 1º de agosto de 2015 (CCC, en lo que sigue), presenta numerosas novedades en el área contractual.

Hay consenso doctrinario en que el CCC regula tres categorías genéricas de contratos: a) los contratos paritarios, discrecionales o clásicos; b) los contratos celebrados por adhesión; y c) los contratos de consumo.

a) Contratos paritarios, discrecionales o clásicos.

Reflejan la estructura tradicional de formación del contrato: éste es el resultado de un acuerdo entre partes que se encuentran en igualdad de condiciones negociales, que regulan sus intereses en un mismo plano de fuerza negocial. Es el tipo de contrato que previó Vélez en el Código Civil y en el Código de Comercio, que reflejaba una larga tradición en la materia. El lector, sin embargo, no encontrará las expresiones “contrato paritario” ni “contrato discrecional” en ninguna parte del nuevo ordenamiento. Esta categoría surge y se deduce de la regulación general del contrato prevista en los arts. 957 a 1091 y concs.

b) Contratos por adhesión.

Es la gran novedad del nuevo sistema. En esta categoría contractual un sujeto, llamado predisponente, que puede ser un vendedor, locador, prestamista, fiduciario, licenciante, concedente, franquiciante y muchos etcéteras, impone el contenido del contrato a su contraparte, denominada adherente, quien solo puede aceptar o rechazar el acuerdo, mas no modificarlo. Son acuerdos en los que no hay negociación previa, o la hay mínimamente. Reflejan una porción gigante de la contratación moderna, sobre todo la verificada a partir del siglo XX en adelante, y están claramente vinculados con la industrialización y mecanización de los procesos productivos, y con la fabricación y comercialización de bienes y servicios en serie, en masa o en escala. Los contratos bancarios en general, el transporte, la afiliación a empresas de medicina prepaga, la telefonía móvil, el tiempo compartido y los paquetes turísticos, la adhesión a fideicomisos, numerosas locaciones y

contratos de obra, y muchísimos otros supuestos negociales constituyen ejemplos cotidianos de este tipo contractual.

Si bien desde hace décadas esta categoría ya estaba aceptada en doctrina y jurisprudencia, no tenía anclaje legal hasta ahora, salvo, tal vez, por su alusión en el art. 38, ley 24.240 de Defensa del Consumidor. El nuevo Código recepta expresamente la categoría de contratos por adhesión en los arts. 984 a 989. Si bien esas reglas están ubicadas dentro del Título “Contratos en general” que regulan la teoría clásica y moderna del contrato, constituyen una especie nueva que tiene eco en otras numerosas áreas del Código, como por ejemplo:

- Art. 1062 en materia de interpretación de los contratos;

- Art. 1310 relativo a la nulidad de algunas cláusulas predispuestas en ciertos transportes de cosas;

- Art. 1634 en supuestos vinculados a la cesión de deudas;

- Art. 1651 en materia de arbitraje;

- Arts. 1720 y1743 relativos a validez o invalidez de ciertas cláusulas en el ámbito de la responsabilidad civil;

- Art. 2568 sobre nulidad de ciertas cláusulas en materia de caducidad de derechos.

Se aclaran tres cosas:

a) los contratos por adhesión son contratos válidos en sí, aunque es frecuente que sean vehículo para insertar las denominadas cláusulas abusivas, de las que se ocupa especialmente el art. 988;

b) las cláusulas abusivas no se encuentran únicamente en los contratos por adhesión, aunque es su hábitat natural (arg. art. 1117 y concs.); y

c) las cláusulas abusivas son una manifestación, en el ámbito contractual, del principio más general receptado en el art. 10 sobre prohibición del ejercicio abusivo de los derechos, replicado también en numerosas normas, figuras e instituciones del nuevo ordenamiento: arts. 11, 775, 794, 1011, 1120, 1732, 1963, 2152, entre otras disposiciones.

c) Contratos de consumo.

Esta categoría genérica no constituye en verdad una novedad legal, dado que ya estaba tratada en la legislación especial –ley 24.240 de Defensa del Consumidor–,y ahora aparece reconocida en el nuevo Código.

Esta modalidad contractual posee, por ello, una doble regulación legal:

1) la ley 24.240, su decreto reglamentario vigente nº 1798/1994 y las decisivas y frecuentemente ignoradas resoluciones nacionales nº 53/2003 y 9/2004, dictadas en su momento por los organismos que precedieron a la Secretaría de Comercio, sobre aspectos centrales del contenido de los contratos de consumo;

2) los arts. 1092 a 1122 que complementan, profundizan, aclaran, amplían y a veces contradicen las normas referidas anteriormente.

El contrato de consumo es una categoría legal, y, para ser tal, supone dos sujetos calificados jurídicamente como consumidor y proveedor: el primero aparece definido en el art. 1º, ley 24.240, y en el art. 1092, CCC, y el segundo, únicamente en el art. 2º, ley 24.240. Pese a ello, el CCC da una noción de contrato de consumo en el art. 1093 que puede traer algunas complicaciones en su interpretación y confronte con la categorización establecida en la 24.240. El contrato de consumo puede ser celebrado paritariamente o por adhesión (doct. arts. 1117 a 1119), aunque esto último es lo más frecuente.

La cuarta categoría de contratos: los contratos “mixtos”.

Algunos autores, (como el Dr. Mariano Esper) hace referencia a la existencia de una cuarta categoría contractual que no aparece regulada propiamente como tal –pese a su incipiente reflejo en el art. 986–, pero que asume importancia mayúscula en la vida negocial entre personas humanas y empresas, y especialmente, entre éstas: es la categoría que denomino contratos mixtos.

La vida negocial entre empresas de igual envergadura y poder de negociación, particularmente, aunque no exclusivamente, presenta con frecuencia hipótesis de negociación de contratos que no quedan encuadradas exactamente en ninguna de las clases indicadas, ya que si bien se suelen utilizar, o se conviene emplear, las condiciones generales de contratación de uno de los contratantes, simultáneamente se negocian numerosos aspectos de la operación o contrato que está gestándose.

Estos supuestos negociales denotan que los acuerdos así logrados no pueden ser encasillados plenamente como contratos paritarios ni como contratos por adhesión puros ni, menos, como contratos de consumo. Constituyen, en verdad, una cuarta clase que se adiciona a las tres mencionadas anteriormente.

La existencia de esta categoría de contratos mixtos exige comprender, entonces, que se trata de acuerdos en los que una parte de su contenido ha sido negociado, mientras que otra parte no lo ha sido, dado que un contratante ha adherido al contenido impuesto por el otro.

La importancia capital de esta cuarto grupo de contratos, en parte discrecionales y en parte por adhesión, reside en el hecho de que el profesional del Derecho interviniente no puede aplicar puramente las normas de una u otra categoría jurídica, sino que debe comprender que el acuerdo que tiene frente a sí requiere de un análisis jurídico mixto, es decir, que debe aplicar las normas correspondientes a cada categoría en la parte del acuerdo que corresponda, y las reglas de la otra categoría en la parte restante; y debe evitar aplicar mecánicamente las disposiciones o pautas de una sola categoría a todo el acuerdo de que se trate. Idéntico mecanismo debe seguirse para interpretar estos contratos.

El contrato mixto requiere, entonces, una aplicación más precisa y adecuada de las normas que regulan los contratos, ya que aplicar llanamente las reglas de los contratos paritarios o de los contratos por adhesión a todo el acuerdo celebrado conllevaría: a) desconocer la voluntad contractual real, en tanto se trata de contratos mixtos, cuyo contenido en parte ha sido predispuesto y en parte ha sido negociado, y por tanto no pertenecen puramente a una única categoría; y b) aplicar inadecuadamente las reglas de Derecho, ya que podría caerse en el error de, por ejemplo, invocar el art. 988 a todo el acuerdo celebrado, cuando ello solo correspondería ser referido a una parte del negocio, a la parte que concretamente fue celebrada por adhesión, mas no a los aspectos paritarios realmente consensuados entre los contratantes.